

1500182-94.2021.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA MILANI

Comarca: Francisco Morato

Foro: Foro de Francisco Morato

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 03/06/2022

... que restou configurado os delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, além das causas de aumento, por estar próximo a estabelecimento de ensino e pelo envolvimento dos adolescentes. a condenação dos réus nos termos da denúncia. Por outro lado, não há que se falar na prática do crime previsto no artigo 244-B do ECA, eis que o concurso de pessoas com os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Francisco Morato

Foro de Francisco Morato

2ª Vara

Rua João Mendes Júnior, 626, Francisco Morato-SP - cep 07910-220

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500182-94.2021.8.26.0544 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500182-94.2021.8.26.0544

Classe - Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2014133/2021 - DEL.POL.FRANCISCO MORATO, 15703961 - DEL.POL.FRANCISCO MORATO, 192/21/203 - DEL.POL.FRANCISCO MORATO, 2014133 - DEL.POL.FRANCISCO MORATO

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Indiciado:

JANAINA DE ANDRADE LEAL e outro

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA MILANI

Vistos.

JANAINA DE ANDRADE LEAL, qualificada nos autos às fls. 29, e DANIEL DA CONCEIÇÃO, qualificado nos autos às fls. 39, estão sendo processados por infração ao artigo artigo 33, caput, c.c. art. 40, inciso III, e artigo 35, caput, todos da Lei nº 11.343/2006 e artigo 244-B, caput, da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), na forma do artigo 69 (concurso material de crimes) do Código Penal, porque, segundo narra a inicial acusatória, no dia 15 de janeiro de 2021, por volta das 17h20min, na Avenida Ulisses Guimarães, nº 2.364, Vila Guilherme, nesta cidade e Comarca de Francisco Morato, os denunciados, nas imediações do estabelecimento de ensino "Escola Estadual Aparecido Roberto Tonelloti", tinham em depósito, para fins de comercialização, 2.251 (duas mil duzentos e cinquenta e uma) porções de cocaína, 1.260 (mil duzentos e sessenta) porções de crack, 480 (quatrocentos e oitenta) porções de "maconha" e 83 (oitenta e três) comprimidos de ecstasy, o que faziam sem

autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como a quantia de R\$ 804,00 (oitocentos e quatro reais), proveniente da venda dos entorpecentes. Consta também que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima referidos, os denunciados, nas imediações do estabelecimento de ensino "Escola Estadual Aparecido Roberto Tonelloti", trazia consigo, para fins de comercialização, 798 (setecentos e noventa e oito) porções de cocaína e 224 (duzentos e vinte e quatro) porções de "maconha". drogas determinam dependência física e psíquica, o que faziam sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Constatam ainda que, nas mesmas circunstâncias de local e tempo acima referidos, os denunciados, associaram-se entre si e com os adolescentes Ana Carolina Oliveira da Silva Fadhl, qualificada às fls. 16, e Wesley de Almeida Pinheiro, qualificado às fls. 17, para praticarem, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de drogas. Consta por fim que, nas mesmas circunstâncias de lugar e tempo acima referidos, os denunciados, corromperam e facilitaram a corrupção dos adolescentes Ana Carolina Oliveira da Silva Fadhl, menor com 17 anos de idade à época dos fatos (fls. 16), e Wesley de Almeida Pinheiro, menor com 17 anos de idade à época dos fatos (fls. 17), com eles praticando a infração penal acima descrita.

Os acusados foram presos em flagrante (fls. 10) e às fls. 121/124 foi convertido o flagrante em prisão preventiva dos acusados.

A denúncia foi recebida (fls. 177/178), adotando-se o rito ordinário para processamento do feito e determinando-se a citação.

A denunciada Janaína foi citada (fls. 210) e apresentou Defesa Prévia (fls. 221/222).

O denunciado Daniel foi citado (fls. 208) e apresentou Defesa Prévia (fls. 205). Em decisão de fls. 204 foram revisadas as prisões dos acusados, mantendo-se o decreto prisional.

Em audiência de instrução e julgamento, o recebimento da denúncia foi ratificado e foram ouvidas quatro testemunhas, havendo insistência na oitiva de uma testemunha ausente. (fls. 270/275).

Às fls. 276 foi revisada a prisão preventiva dos réus, mantendo-se o decreto prisional. Às fls. 284/285 foi designada audiência em continuação.

Em audiência em continuação, foi inquirida uma testemunha e a ré Janaína foi interrogada (fls. 307/311). Às fls. 312/313 foi designada audiência em continuação, ante a não apresentação do réu Daniel.

Em audiência em continuação, o réu Daniel foi interrogado (fls. 325/333 e fls. 347/348).

O Ministério Público, em alegações finais (fls. 325/333), aditou a inicial acusatória, afim de retificar erro material na capitulação jurídica, para que nela conste que os réus foram denunciados como incursos no (i) artigo 33, caput, c.c. art. 40, incisos III e VI, e (ii) artigo 35, caput, c.c. art. 40, incisos III e VI, todos da Lei nº 11.343/2006 e (iii) artigo 244-B, caput, da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), todos c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", na forma do artigo 69 (concurso material de crimes), ambos do Código Penal. Em relação ao mérito alegou que a pretensão punitiva deve ser julgada parcialmente procedente, uma vez que restou configurado os delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, além das causas de aumento, por estar próximo a estabelecimento de ensino e pelo envolvimento dos adolescentes. a condenação dos réus nos termos da denúncia. Por outro lado, não há que se falar na prática do crime previsto no artigo 244-B do ECA, eis que o concurso de pessoas com os adolescentes já foi considerado para a incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas. Assim, a absolvição quanto ao crime de corrupção de menores se impõe, sob pena de bis in idem. Quanto à dosimetria da pena, pleiteou: Na primeira fase de dosimetria da pena, atentando-se ao disposto no artigo 42 da Lei 11.343/06, deve a pena-base ser elevada em razão dos acusados estarem comercializando pedras de crack, pois é notória a altíssima lesividade desta droga. Além disso, deve a pena-base ser elevada em razão da elevada quantidade de entorpecentes apreendidos (mais de 5.000 porções de drogas, de 4 espécies diferentes). Devem, ser considerados os maus antecedentes do corréu

DANIEL. Na segunda fase, deve ser reconhecida a circunstância agravante prevista no art. 61, II, alínea "j" do Código Penal, tendo em vista que os delitos foram cometidos durante o estado de calamidade pública, decorrente da atual pandemia de COVID-19, bem como a circunstância agravante da reincidência em relação ao corréu DANIEL (fls. 109/112). Incide, ainda, a circunstância atenuante da confissão espontânea quanto à corré JANAÍNA. Na terceira fase, incidem as causas de aumento previstas nos incisos III e VI do artigo 40 da Lei 11.343/06. Na terceira fase, inviável a aplicação do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, em razão da reincidência de DANIEL, da sofisticação demonstrada pela conduta criminosa e da elevada quantidade e diversidade de drogas em poder dos réus. O regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o fechado. Vedada a conversão em pena restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 da Lei nº 11.343/06.

A Defesa de Janaína apresentou alegações finais, pleiteando a absolvição quanto ao delito de associação e corrupção de menores. No que se refere à proximidade da escola, que seja excluída a agravante, pois a ré não é de Francisco Morato e não sabia da proximidade da escola, bem como não há prova de que a droga se destinava à menores de idade. Pede que seja considerada a causa de diminuição de pena, pois primária, tinha vínculo empregatício até data recente de 2 meses antes dos atos, não se dedicando à atividade criminosa, sendo que, no caso receberia R\$ 300,00 se conseguisse entregar. Pede a pena no mínimo legal (fls. 325/333).

A Defesa de Daniel, por sua vez, apresentou alegações finais (fls. 335/346), pleiteando a absolvição do réu com fundamento no art. 386, inciso V e VII, do Código de Processo Penal, pois não existe nos autos nenhuma prova dos delitos imputados ao acusado. Sustenta que o réu possui domicílio fixo, trabalho, reside com sua família e não apresenta histórico de periculosidade. Requer, em caso de eventual condenação pelo crime de tráfico de drogas, que se considere a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, pois estão presentes os seus requisitos autorizadores, com aplicação do regime aberto para o cumprimento da pena, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e que o réu possa apelar em liberdade.

Documentos juntados: auto de exibição/apreensão da droga, objetos e dinheiro (fls. 27/28); laudo de constatação da droga (fls. 61/65); croqui do local dos fatos (fls. 162); laudo pericial químico toxicológico (fls. 163/166); Laudo pericial da mochila (fls. 167/168); guia de depósito judicial (fls. 42); Folha de antecedentes de Janaína (fls. 95) e Certidão de distribuição criminal (fls. 108); Folha de antecedentes de Daniel (fls. 96/98) e Certidão de distribuição criminal (fls. 109/112); laudo dos celulares (fls. 253/256).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é procedente em parte, sendo a hipótese, na esteira da manifestação ministerial, de "emendatio libelli" (artigo 383, do Código de Processo Penal) para constar que os réus estão incurso: (I) artigo 33, caput, c.c. art. 40, incisos III e VI, e (II) artigo 35, caput, c.c. art. 40, incisos III e VI, todos da Lei nº 11.343/2006 e (III) artigo 244- B, caput, da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), todos c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", na forma do artigo 69 (concurso material de crimes), ambos do Código Penal, circunstância esta descrita na exordial.

Ressalta-se que o acusado, em processo penal, "se defende dos fatos, sendo irrelevante a classificação jurídica constante da denúncia ou queixa. Segundo o princípio da correlação, a sentença está limitada apenas à narrativa feita na peça inaugural, pouco importando a tipificação legal dada pelo acusador. Desse modo, o juiz poderá dar aos eventos delituosos descritos explícita ou implicitamente na denúncia ou queixa a classificação jurídica que bem entender, ainda que, em consequência, venha a aplicar grave, sem necessidade de prévia vista à defesa, a qual não poderá alegar surpresa, uma vez que não se defendia da classificação legal, mas da descrição fática da infração penal" (in Código de Processo Penal Comentado; Fernando Capez, Rodrigo Henrique Colnago. São Paulo : Saraiva, 2015, p.

Sobre o tema é o ensinamento doutrinário: "A emendatio libelli não implica em julgamento ultra petita, porque não há mudança, alteração do pedido. O juiz só dá ao fato imputado na inicial, do qual o réu se defendeu e restou provado na instrução, outro enquadramento legal (definição jurídica diversa), conforme o art. 383 do CPP. Pouco importa se a pena, em razão de definição jurídica diversa, aumenta, diminui ou permanece inalterada. Nenhuma providência se impõe ao juiz. Repita-se: na emendatio libelli não há inovação da acusação, não há alteração do pedido; há simplesmente uma corrigenda da peça acusatória. Diz-se que a emendatio libelli decorre da autonomia decisória do juiz, pois é livre para interpretar os fatos e o direito, fazendo-o, no entanto, sempre de forma fundamentada. Daí as máximas do jura novit curia (livre dicção do direito) – o juiz conhece o direito – e o narra mihi factum dabo tibi jus (narra-me o fato e te darei o direito). O que se verifica na emendatio libelli é um erro, um equívoco na capitulação, seja ele material ou de opinião. Terá aplicação tanto na ação penal pública quanto na privada, em todas as suas espécies. O juiz, em face de emendatio libelli, sentenciará de logo, de plano, sem prévia oitiva das partes, cabendo as mesmas, na discordância, o recurso de apelação contra a sentença, quando a matéria poderá ser discutida." (in Curso de Processo Penal, Hidejalma Mucio, São Paulo: editora Método, 2ª ed., 2011, páginas 1.496/1.497).

A materialidade e autoria dos delitos apurados nos autos estão comprovadas pelos depoimentos prestados no curso do inquérito policial e em Juízo, bem assim, laudo de constatação preliminar da droga e laudo de exame de substâncias psicoativas, auto de apreensão da droga/dinheiro, croqui do local dos fatos e guia de depósito de dinheiro apreendido.

A ré JANAÍNA DE ANDRADE LEAL foi interrogada na fase policial (fls. 18) e afirmou: "Que gostaria de esclarecer que no dia de hoje, através de uma colega que não se recorda o nome, foi contactado por um indivíduo desconhecido, o qual nesta tarde a encontrou no município de Caieiras-SP, e lhe pediu para entregar uma mochila com entorpecentes neste município de Francisco Morato, em uma residência localizada à Avenida Ulisses Guimarães, nº 2364, Vl. Guilherme, Francisco Morato-SP, sendo que, através do aplicativo Uber acionou um veículo, e quando chegou no endereço mencionado, após descer do veículo e dirigir-se para o portão do imóvel, notou que haviam policiais no local com algumas pessoas detidas, e de imediato tentou se desvencilhar voltando para o veículo, contudo, foi detida em seguida, e antes dos policiais militares a perguntarem sobre o que estava fazendo ali, esclareceu que estava com drogas na mochila e foi contactada para entregá-las naquele endereço. Esclarece que nunca esteve presa. Que esta arrependida. Que o motorista do UBER que não sabe o nome, não sabe o que trazia consigo." Em juízo nega os fatos descritos na denúncia; que estava no seu bairro, no Jaraguá, sendo que, uma amiga lhe chamou e apresentou um homem que ofereceu dinheiro, R\$ 300,00, para levar para Francisco Morato, o qual receberia no retorno; que aceitou e recebeu as drogas (100 parangas - maconha e 100 K2 – farelo da maconha mas mais forte e produzida em laboratório), colocadas na mochila preta; que chegando em Baltazar Fidelis chamou Uber e colocou o número da casa, tendo-a levado até a rua, mas como estava trânsito pediu para não deixar em frente a casa, sendo que, desceu, veio a viatura e a abordou perguntando o que tinha na mochila; que foi abordada por dois policiais juntos, um masculino e outra feminina, ao lado de uma lanchonete; que os policiais William e Alex chegaram depois e pegaram a mochila; que foi colocada dentro da viatura; que não chegou a entrar em casa nenhuma; que na delegacia se deparou com os demais envolvidos na denúncia; que na Delegacia veio um policial colocou mais drogas ao lado da mochila, se deparando com as setecentas e pouco porções de cocaínas; que nega que portava cocaína; que nega conhecer os demais envolvidos na denúncia; que não conhecia nenhum dos policiais; que a interroganda quem esclareceu que veio de Uber, no veículo fiat de cor vermelho, tendo os policiais ido atrás dele; que foi abordada pela primeira viatura e esta continuou com a ré encostada na calçada e após chegou a segunda viatura; que estava chovendo e vidro embaçado, não sendo possível ver se

tinham mais pessoas dentro das viaturas; que em momento algum levaram a depoente para dentro de alguma casa; que em momento algum os policiais falaram sobre a existência de mais drogas e a conexão da ré com os demais relacionados na denúncia; que o policial William respondeu ao questionamento da ré no sentido de que ela responderia apenas por aquilo que pertencia à ela e não sobre as drogas que na delegacia colocaram ao lado da sua mochila; que quanto ao se interrogatório policial nega que tivesse qualquer situação em Caieiras e afirma que na realidade não houve interrogatório policial; que nunca tinha estado em Francisco Morato (fls. 310/311).

O réu DANIEL DA CONCEIÇÃO foi interrogado na fase policial (fls. 19) e afirmou: "Que já foi preso por tráfico na cidade de São Paulo, em 2016. Que, estava na casa no local da abordagem dos policiais militares apenas usando "maconha" com ANA CAROLINA e WESLEY. Que, não sabe dizer de quem eram as drogas encontradas pelos policiais militares na casa. Que, não conhece a pessoa de JANAINA. Que, com relação aos fatos se reserva para manifestar-se somente em juízo." No interrogatório judicial nega os fatos descritos na denúncia; que três dias atrás dos fatos, saiu da cidade em que morava (Perus) e veio morar em Francisco Morato, uns 20 dias antes dos fatos (Vila Guilherme, cerca de 500 metros da Avenida Ulisses Guimarães) e há 3 dias antes foi comprar maconha, sendo que, houve a abordagem da polícia; que nestes fatos o réu estava junto da sua esposa, sendo falado a ela que o réu responsável pela biqueira onde estavam e que queriam fazer acerto, sendo inclusive a esposa dado o endereço do casal; que 3 dias após isto estava andando de moto com sua esposa, quando visualizou os policiais que fizeram o quadro, tendo o policial perguntado se era o réu que correu na data anterior, tendo o réu afirmado que sim porque ele já cumpriu pena e o policial afirmou que ele seria preso de novo sem nada dever; que levaram o réu até uma casa onde havia um menor ao lado de uma sacola verde, tendo o policial afirmado que a droga lá existente era do réu, tendo ele negado, mas o policial afirmou que por não ter feito acerto com eles, ele seria preso sim pela ocorrência forjada; que na sequência chegaram as viaturas; que o réu não foi flagrado dentro da casa; que o dono do estabelecimento presenciou que o réu não estava na residência quando houve a abordagem policial; que os policiais que fizeram a abordagem 3 dias antes era um alemãozinho e outro branquinho, cabelo preto e grande e de olho puxado, confirmando que eles que fizeram a abordagem do presente boletim de ocorrência; que estava na Avenida Ulisses Guimarães, próximo à escola; que no dia dos fatos, estava com sua esposa passando pela Avenida Ulisses Guimarães e cerca de 2 metros do número 2.364 foi abordado pela viatura; que após abordagem foi levado para a residência deste número onde estava o adolescente do sexo masculino, somente; que sua esposa chama-se Ana Carolina, que na época era menor de idade; que hoje sua esposa foi visita-lo no presídio e afirmou que conversou com Wesley logo depois que se deram os fatos, para que se o B.O. fosse dele era para ele segurar, mas ele não respondeu; que não conhece a corré Janaína; que depois de sair da casa, colocaram o réu e Wesley numa viatura e sua mulher Ana Carolina em outra, tendo aguardado numa esquina; que as viaturas ficaram num beco até que retornaram para a Avenida Ulisses Guimarães onde estava sendo abordada Janaína, próxima à casa onde estava Wesley, tendo levado o réu, Wesley e Ana Carolina para junto de Janaína (fls. 347/348).

A testemunha de acusação WILLIAM SANTOS DUARTE na fase policial (fls. 11/12) relatou: "Que juntamente com o seu colega de farda, apresentam os adolescentes WESLEY DE ALMEIDA PINHEIRO e ANA CAROLINA OLIVEIRA DA SILVA FADHL e maiores imputáveis JANAINA DE ANDRADE LEAL e DANIEL DA CONCEICAO, após capturá-los em situação de tráfico de drogas. Que na presente data receberam notícia anônima via COPOM, detalhando que o imóvel situado na Avenida Ulisses Guimarães, nº 2364, Vila Guilherme, neste município de Francisco Morato, algumas pessoas estariam ocultando e mantendo em depósito entorpecentes para futura distribuição nas biqueiras de trafico de drogas nesta urbe. Deste modo, em decorrência das informações repassadas, os Militares se deslocaram ao local informado, onde encontraram o adolescente WESLEY DE ALMEIDA PINHEIRO, defronte ao imóvel noticiado, sendo que o adolescente WESLEY, que ao notar a chegada da polícia MILITAR, ingressou rapidamente no imóvel descrito na notícia anônima, razão para qual foi perseguido

dentro da casa, local onde os militares flagraram também DANIEL DA CONCEIÇÃO e a menor ANA CAROLINA embalando entorpecentes, quais sejam 2251(duas mil duzentos e cinquenta e uma) porções de "cocaína"; 1260(Um mil, duzentos e sessenta) porções de "crack" , 480(quatrocentos e oitenta) porções de "maconha" e 83(oitenta e três) comprimidos aparentando ser "ecstasy", encontrando na sala da residência ainda, a quantia de R\$ 804,00(oitocentos e quatro reais) em notas diversas e 06 (seis) telefone celulares, sendo que puderam notar que o menor WESLEY atuava como "olheiro do trafico" para anunciar a chegada de viaturas no local. Ademais, informam que DANIEL e a menor ANA CAROLINA foram localizado na sala da residência, embalando as drogas supra mencionadas, sendo que o menor WESLEY adentrou no local para comunicar a chegada dos Militares, porem, conseguiram se aproximar rapidamente e efetuar a captura dos mesmos. Que ao efetuarem as prisões na residência supra mencionada, no momento em que ainda estavam no local, vislumbraram a chegada da adolescente JANAINA DE ANDRADE LEAL, a qual estava com uma mochila nas costas, e ao tentar entrar no imóvel durante a vistoria pela Polícia Militar, fora capturada, sendo que mediante busca pessoal localizaram dentro da mochila que JANAINA trazia consigo para abastecer a residência, sendo localizado 798 (setecentos e noventa e oito) porções de "cocaína" e 224 (duzentos e vinte e quatro) porções de "maconha", sendo que conseguiram observar que JANAINA fora deixada no local pela testemunha JONAS LOPES DOS SANTOS, o qual estava com o veículo Fiat/Uno de BYX- 7J84, pois o mesmo é motorista de aplicativo de transporte UBER, o qual afirmou que na presente data foi chamado pelo aplicativo UBER, tendo pego JANAINA em Franco da Rocha_SP próximo a estação do Trem de "Baltazar Fidelis" e levado para a Avenida Ulisses Guimarães, nº 2364, Vila Guilherme, neste município de Francisco Morato, sendo que observou que a mesma desceu do veículo com a mochila apreendida pelos Militares, mas não sabia o que a mesma trazia consigo. Por fim, os Militares informam que todos os conduzidos confessaram o delito, admitiram estarem na prática do crime de tráfico de entorpecentes, e estavam separando as drogas para venda. Ademais, os Militares informam que o local dos fatos fica há cerca de 450 (quatrocentos e cinquenta metros) de distância da Escola Estadual Aparecido Roberto Tonelloti, situado na Av. Ulisses Guimarães, 1976, Vila Guilherme, Francisco Morato - SP. Deste modo, conduziram todos os envolvidos e os entorpecentes a esta Unidade Policial para adoção das medidas de Polícia Judiciária pertinentes." Inquirido em Juízo relatou que havia feito prisão de 3 indivíduos numa residência e quando os conduzia para a Delegacia, Janaína desceu num veículo e entrou num corredor que dá à residência, sendo que, quando visualizou a polícia, tentou retornar, sendo abordada e confessou que estava com drogas (maconha e cocaína); que as drogas de Janaína eram parecida com as drogas que estavam com os três indivíduos, mesma embalagem etc; que Janaína adentrou ao portão que dá acesso à casa; que o depoente abordou Janaína e depois o motorista do Uber que estava para sair; que no local os menores não chegaram falar que conheciam Janaína, mas ela confessou que ela quem fazia a entrega nesses lugares; que Daniel estava dentro do imóvel, mais dois menores, um homem e outra mulher; que avistaram o menor na porta e quando este visualizou a polícia, entrou na residência; que foram ao encalço; que a casa era uma cozinha e quarto; que Daniel estava dentro da casa sentado no colchão contando o dinheiro; que o menor que tinha corrido para dentro da residência estavam de frente para os outros dois; que no terreno havia a casa mencionada e mais duas ou três mais para traz no fundo do corredor (fls. 274).

A testemunha de acusação ALEX FABIANO PANZANI na Delegacia (fls. 13/14) afirmou: "Que juntamente com o seu colega de farda, ora condutor, apresentam os adolescentes WESLEY DE ALMEIDA PINHEIRO e ANA CAROLINA OLIVEIRA DA SILVA FADHL e o maiores imputáveis JANAINA DE ANDRADE LEAL e DANIEL DA CONCEIÇÃO, após capturá-los em situação de tráfico de drogas. Que na presente data receberam notícia anônima via COPOM, detalhando que o imóvel situado na Avenida Ulisses Guimarães, nº 2364, Vila Guilherme, neste município de Francisco Morato, algumas pessoas estariam ocultando e mantendo em depósito entorpecentes para futura distribuição nas biqueiras de trafico de drogas nesta urbe. Deste modo, em decorrência das informações repassadas, os Militares se deslocaram ao local informado, onde encontraram o adolescente WESLEY DE ALMEIDA PINHEIRO, defronte ao imóvel noticiado, sendo que o

adolescente WESLEY, que ao notar a chegada da polícia MILITAR, ingressou rapidamente no imóvel descrito na notícia anônima, razão para qual foi perseguido dentro da casa, local onde os militares flagraram também DANIEL DA CONCEIÇÃO e a menor ANA CAROLINA embalando entorpecentes, quais sejam 2251(duas mil duzentos e cinquenta e uma) porções de "cocaína"; 1260(Um mil, duzentos e sessenta) porções de "crack" , 480(quatrocentos e oitenta) porções de "maconha" e 83(oitenta e três) comprimidos aparentando ser "ecstasy", encontrando na sala da residência ainda, a quantia de R\$ 804,00(oitocentos e quatro reais) em notas diversas e 06(seis) telefone celulares, sendo que puderam notar que o menor WESLEY atuava como "olheiro do trafico" para anunciar a chegada de viaturas no local. Ademais, informam que DANIEL e a menor ANA CAROLINA foram localizado na sala da residência, embalando as drogas supra mencionadas, sendo que o menor WESLEY adentrou no local para comunicar a chegada dos Militares, porem, conseguiram se aproximar rapidamente e efetuar a captura dos mesmos. Que ao efetuarem as prisões na residência supra mencionada, no momento em que ainda estavam no local, vislumbraram a chegada da adolescente JANAINA DE ANDRADE LEAL, a qual estava com uma mochila nas costas, e ao tentar entrar no imóvel durante a vistoria pela Polícia Militar, fora capturada, sendo que mediante busca pessoal localizaram dentro da mochila que JANAINA trazia consigo para abastecer a residência, sendo localizado 798 (setecentos e noventa e oito) porções de "cocaína" e 224 (duzentos e vinte e quatro) porções de "maconha", sendo que conseguiram observar que JANAINA fora deixada no local pela testemunha JONAS LOPES DOS SANTOS, o qual estava com o veículo Fiat/Uno de BYX- 7J84, pois o mesmo é motorista de aplicativo de transporte UBER, o qual afirmou que na presente data foi chamado pelo aplicativo UBER, tendo pego JANAINA em Franco da Rocha_SP próximo a estação do Trem de "Baltazar Fidelis" e levado para a Avenida Ulisses Guimarães, nº 2364, Vila Guilherme, neste município de Francisco Morato, sendo que observou que a mesma desceu do veículo com a mochila apreendida pelos Militares, mas não sabia o que a mesma trazia consigo. Por fim, os Militares informam que todos os conduzidos confessaram o delito, admitiram estarem na prática do crime de tráfico de entorpecentes, e estavam separando as drogas para venda. Ademais, os Militares informam que o local dos fatos fica há cerca de 450 (quatrocentos e cinquenta metros) de distância da Escola Estadual Aparecido Roberto Tonelloti, situado na Av. Ulisses Guimarães, 1976, Vila Guilherme, Francisco Morato - SP. Deste modo, conduziram todos os envolvidos e os entorpecentes a esta Unidade Policial para adoção das medidas de Polícia Judiciária pertinentes." Em juízo relatou: que houve denúncia anônima de que pela Av. Ulisses Guimarães haviam indivíduos na prática de tráfico numa residência; que no local havia um menor de idade entrando na residência; que na residência havia mais um maior de idade e outra menor; que ambos estavam embalando entorpecente; que se depararam com Janaína entrando na residência e tentou se evadir ao ver a polícia; que Janaína estava com mochila e no interior havia entorpecente; que o entorpecente de Janaína tinha semelhança com o entorpecente que estava na residência; que Janaína confessou que ela quem entregava o entorpecente para aquela residência; Relata que o menor de idade avistou a polícia e entrou correndo para a residência; que Janaína foi abordada quando estava na entrada da casa; que o veículo parou bem em frente a casa e Janaína tinha adentrado no corredor e quando percebeu a equipe tentou se evadir e foi abordada; que a viatura não estava em frente ao portão, tendo ficado um pouco afastada da casa; que não fez pergunta se Janaína conhecia as pessoas da casa; que Janaína falou que fazia o transporte do entorpecente até a residência; que participou da prisão de Daniel; que quando entrou no imóvel Daniel estava no interior no cômodo do fundo, sendo 2 cômodos, ele estava no segundo, sentado com uma menor. Quando o menor de idade correu para dentro do imóvel, Daniel estava no referido cômodo; que havia um colchão no chão e eles estavam fazendo a separação da droga; que reperguntado sobre a situação do menor que correu para residência disse que não se recorda claramente qual a situação deste dentro da casa, se esta em pé ou sentado com as drogas, mas que o maior e a adolescente com certeza estavam sentados no colchão separando as drogas; que não se recorda se havia droga em poder do menor, mas com certeza as drogas estavam no chão próxima aos indivíduos no colchão (fls. 275).

A testemunha de acusação JONAS LOPES DOS SANTOS na Delegacia (fls. 15) afirmou: "Que trabalha como motorista de aplicativo UBER, veículo Fiat/Uno de BYX-7J84, sendo que por volta das horas foi acionado pelo aplicativo UBER, para pegar a pessoa de JANAINA DE ANDRADE LEAL na estação do Trem da CPTM de "Baltazar Fidelis" na cidade de Franco da Rocha-SP, sendo que de início ela solicitou que a levasse até a Rua Recife, n. 714, bairro Cento e Vinte, de Francisco Morato-SP, porem durante o trajeto JANAINA solicitou que a levasse até uma residência na Avenida Ulisses Guimarães, nº 2364, Vila Guilherme, neste município de Francisco Morato-SP, sendo que observou que JANAINA estava com uma mochila, tendo deixado JANAINA naquele local, tendo a corrida custado o valor de R\$ 11,73 (onze reais e setenta e três centavos), pago com quinze reais por JANAINA, a qual não pediu troco do valor pago. Que em seguida, ao deixar JANAINA defronte a referida residência, quando manobrava o veículo para ir embora, Policiais Militares que estavam dentro da casa abordaram o seu veículo, sendo que de pronto parou e disse aos Militares que havia acabado de deixar a mesma no local, sendo que é motorista de UBER, quando foi convidado a vir a Delegacia. Que não sabia que JANAINA trazia drogas, mas visualizou que a mesma trazia uma mochila. Que gostaria de esclarecer que no aplicativo UBER, a solicitante estava com o nome de SIMONE, mas depois veio saber que se tratava de JANAINA DE ANDRADE LEAL. Que não sabe dizer se dentro da residência da Avenida Ulisses Guimarães, nº 2364, Vila Guilherme, neste município de Francisco Morato-SP, sendo que não conhecia a mesma anteriormente, bem como não conhecia os outros conduzidos. Que vai fornecer o trajeto da corrida do aplicativo UBER, pois vai solicitar a empresa e vai fornecer para a Justiça." Em juízo relatou que pegou passageiro na estação Baltazar Fidélis e levou até Francisco Morato (Rua Recife); que ela pagou R\$ 11,76 e entregou R\$ 15,00 e que não queria troco; que ela desceu alegando que iria entregar uma placa de computador, extra deu mais R\$ 20,00 ao depoente para que depois a levasse até à Rua Ulisses Guimarães, desceu do carro e em seguida foi abordada pela polícia; que não reparou se ela estava com drogas na mochila; que quando Janaína foi abordada pelos policiais, já havia descido do carro e estava entrando em uma residência, mas não tem certeza se ela chegou realmente a entrar ou foi abordada na porta. Em seguida o depoente também foi abordado pela polícia (fls. 273).

A testemunha de acusação ANA CAROLINA OLIVEIRA DA SILVA FADHL na Delegacia (fls. 16) fez uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio. Em juízo relatou que estava em casa e falou que iria para a casa de sua mãe, sendo que, os policiais pararam elas na frente da casa e as colocaram para dentro; que já falou tudo o que tinha que falar na primeira audiência; que morava na CDHU com ele e por volta das 17/18 horas iria para a casa da mãe quando foi abordada; que a genitora mora em Cajamar; que a apreensão da depoente ocorreu em Morato, na Ulisses Guimarães; que não conhecia Janaína, mas apenas Daniel que era seu namorado e ainda é; que Daniel é pizzaiolo; que nega que estivesse embalando droga no dia dos fatos; que por conta destes fatos ficou 4 dias internada em Mairiporã, mas não recebeu medida; que Janaína chegou após a depoente ter sido colocada pelos policiais dentro da casa; que na delegacia não falou nada porque não perguntaram nada; que não viu localizarem algo com Janaína, pois a depoente já estava na viatura e depois os policiais apareceram com ela; que namora com Daniel há 2 anos, sabendo que ele já teve problema com o crime de drogas, mas depois soube que ele largou o crime e assim eles reataram; que não conhece Wesley; que estava há cerca de 3 minutos de casa, na mesma avenida onde moravam; que não conhece Wesley; que não tinham feito uso de maconha; que os policiais abordaram a depoente com Daniel enquanto estavam na moto no trajeto para a casa da mãe e os levaram até uma casa que ficava em frente onde estava Wesley (que a depoente já estava passando em frente a esta casa quando da abordagem) que a depoente até então não conhecia; que nesta casa os policiais encontraram um saco preto no último cômodo contendo drogas; que não conhecia os policiais (fls. 309)

A testemunha de acusação WESLEY DE ALMEIDA PINHEIRO na Delegacia (fls. 17) declarou: "Que, é usuário de "maconha" e que no dia de hoje estava na residência do local dos fatos para fumar "maconha", juntamente as pessoas de DANIEL e ANA CAROLINA; Que, não sabe dizer de quem era as drogas apreendidas pela polícia

militar na casa; Que, não conhece a pessoa de JANAINA encontrada com uma mochila com drogas; Que, demais fatos se reserva para manifestação em juízo." Em juízo relatou: que estava na casa quando os policiais foram lá; que na casa estava o réu e sua mulher e também estava a parceira para entrar; que foram fumar baseado com parceiro; que estava no local há 30 minutos e os policiais apareceram; que no momento em que chegou não tinha visto droga mas não também não tinha reparado na sacola em que posteriormente a polícia achou a droga; que não conhecia Janaína; que quando ela chegou no local os policiais prenderam-na; que o parceiro do depoente é Daniel; que conhecia os policiais por enquadro de momento, mas não se recorda dos nomes, sendo uma mulher e os outros homem; que não sabe se eles tinham motivo para prejudica-lo; que nunca tinha visto Janaína; que estava o depoente, Daniel e a mina que iria arrumar um trampo; que a menor já estava na casa; que quando o depoente entrou com Daniel os policiais entraram na sequencia; que estavam subindo as escadas e na sequencia que entraram na casa os policiais abordaram; que estavam dentro da viatura quando Janaína foi abordada; que não sabe se Janaína foi abordada saindo do uber ou entrando na casa; que a viatura estava um pouco longe, na primeira curva à esquerda; que não dava para ver nem ao certo o uber; que só viu os policiais jogando Janaína para dentro da viatura e mostraram a droga, não tendo visto o início da abordagem dela; que conhecia Daniel há pouco tempo, com a intenção de arrumar um emprego; que o depoente e Daniel se conheciam e estavam indo para a casa local dos fatos porque foi dito que lá conseguiriam um emprego, mas pararam no corredor que dá acesso à casa para fumar um baseado; que não consegue explicar se a adolescente também parou para fumar o baseado, ora dizendo que estavam os três para fumar, ora falando que não conseguiu observar se a adolescente estava fumando; que na sequencia de terem fumado o baseado entraram na residência os três e cerca de uns 3 minutos após a polícia chegou; que ao entrarem na casa perceberam que não tinha a situação do emprego como eles estavam achando; que a adolescente também estava no local pelo emprego; que não conhecia a adolescente. Ressalto que o depoimento do adolescente apresenta uma fala confusa sobre a dinâmica dos fatos, não conseguindo se extrair uma versão unilinear, podendo apenas concluir que ele nega que ele, Daniel ou a adolescente tivesse relação com a droga que os policiais teriam encontrado na residência dentro de alguma sacola e que a droga não estaria exposta como afirmado pelos policiais.

Contudo, os policiais que participaram da ação, testemunhas de acusação, apresentaram um depoimento coeso na fase policial, o qual foi reafirmado judicialmente:

O testemunho do policiais foram coesos e encontram respaldo nas demais provas amealhadas aos autos. Nesse sentido:

"Depoimentos de policiais. Presunção de idoneidade. São idôneos os depoimentos de policiais civil e militares, prestados na polícia e em Juízo, de forma coerente e em harmonia com outros elementos probatórios existentes nos autos, podendo embasar decreto condenatório" (RJTJERGS 182/132).

TESTEMUNHO DOS POLICIAIS QUALIFICADO

É importante salientar que a lei penal não furta valor ao testemunho dos agentes de segurança, na medida em que não os dispensa do compromisso de dizer a verdade e nem os poupa do crime de falso testemunho, caso venham a sonegar ou adulterar os fatos. Há de se levar em conta que os acusados e os policiais não se conheciam até então, de forma que estes não tinham motivos para acusá-los leviana e gratuitamente.

Aliás, nem teria sentido conferir-lhes a lei determinada tarefa para depois, quando viessem prestar contas de sua atuação, negar-lhes valor aprioristicamente, por preconceituosa admissão de que não dizem a verdade:

"O depoimento de policial obedece os mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição funcional" (TJSP, RT 752/586);

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo sob garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que

esse servidor do estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam, com outros elementos probatórios idôneos" (STF, HC nº 74.608-0, Rel. Min. Celso de Mello, j. 18/02/97, DOU de 11/04/97, p. 189);

"Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário é de idoneidade destas testemunhas, ainda mais quando os seus depoimentos são seguros precisos e uniformes desde a sede inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição" (TJSP, RT 614/275);

"Os policiais não são proibidos de prestar depoimento nos processos de cuja fase policial tenham participado, seja efetuando a prisão do agente, seja apreendendo o objeto do crime. De outro lado, a declaração de inidoneidade é específica e não genérica, não podendo abranger toda uma categoria de pessoas, devendo ser alegada e demonstrada em cada caso" . (TJMG, RT 604/407).

Como visto, os depoimentos dos agentes de segurança são claros quanto à efetiva participação dos réus no crime de tráfico e nada há nos autos há infirmar a lisura dos trabalhos policiais, lembrando que pequenas divergências entre as declarações prestadas, sequer existentes na hipótese, não bastam, por si só, para infirmá-las. Além disso, não demonstrou a Defesa, como seria de rigor, eventual motivo que teriam os policiais civis para mentir em juízo, não se desincumbindo do ônus que lhe competia (artigo 156, do Código de Processo Penal). Nesse sentido:

"PROVA - Pequenas divergências entre os relatos das testemunhas - Irrelevância - Validade. As pequenas contradições na prova decorrem das próprias imperfeições do psiquismo humano, agravadas, em geral, pelas condições em que a prova é realizada. Assim, de se desconfiar do testemunho demasiado perfeito, sendo, sim, importante, verificar se, embora discrepantes em detalhes mínimos, concordam os depoimentos nos pontos essenciais, quanto às circunstâncias decisivas do fato" (TACrimSP - Ap. nº 583.153/2 - 7ª Câ. - Rel. José Habice - J. 05.04.90 - RJDTACRIM 6/78).

A Defesa tenta, em vão, diminuir o valor dos depoimentos prestados pelos policiais, o que não se sustenta diante do quadro probatório existente e dos elementos de convicção formados. Nesse ponto, é preciso ficar claro que a inexistência de testemunhas civis e 'eventuais compradores' no ato da prisão em flagrante não o invalida, cumprindo ressaltar que em delitos da espécie, como cediço, ainda que populares presenciem a atividade criminosa, estes não querem se identificar com medo de represálias por parte dos criminosos.

CONCLUSÃO

Portanto, demonstrado que os réus tinham em depósito a droga, o seu destino tem que ser analisado pelos demais elementos que cercam a questão.

No caso dos autos, a grande quantidade e variedade de droga apreendida, a forma como estava dividida e sendo embalada para pronta distribuição, os antecedentes criminais do réu Daniel e, ainda, o depoimento das testemunhas, levam à certeza de que os réus transportavam e tinham em depósito as drogas na ocasião para fins de mercancia, impondo-se, pois, a condenação.

Assevero não ser crível a versão do réu Daniel de que estava na Rua quando foi abordado e que foi levado até a residência (local dos fatos), uma vez que a testemunha Wesley confirmou que ele, o réu Daniel e a menor de idade Ana Carolina estavam na residência no momento da abordagem.

IRRELEVÂNCIA ATOS DE MERCANCIA

Destaca-se que o crime de tráfico de entorpecente é de mera conduta, bastando, para a sua consumação, a prática de qualquer um dos núcleos verbais do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, independentemente da concretização ou não da entrega ao destinatário, pelo que a simples conduta do réu, consistente em "possuir", "guardar" e "trazer consigo" a substância entorpecente, já é suficiente para caracterização do delito:

A propósito: "Nunca é demais lembrar, de outro lado, que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a

droga para esta destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige resultado" (TJ/SP – Apel. Crim. nº 990.09.088010-4 – 5ª Câmara Criminal - Campinas – v.u. – j. 03.09.09 – Rel. Des. Pinheiro Franco).

No mesmo sentido:

"O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente" (RT 776/663); "Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido" (RT 729/542).

"Cabe ressaltar que para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessária a prova flagrante do comércio ilícito, sendo suficientes os elementos indiciais apurados no caso concreto, bem como as circunstâncias da prisão para evidenciar tal atividade ilícita". (TJ/SP – Apel. Crim. nº 990. 09.235417-5 – 14ª Câmara Criminal - Campinas – v.u. – j. 11.03.10 - Rel. Des. Fernando Torres Garcia).

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

Quanto ao delito previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06, ou seja, associação para o tráfico, não restou bem demonstrado nestes autos. É que, nada obstante, a norma em comento descreve a conduta típica de "associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei", não configura o delito o simples concurso de agentes.

Nesse ponto, muito bem colocadas as anotações de Vicente Greco Filho e João Daniel Rassi: "Parece-nos, todavia, que não será toda vez que ocorrer concurso que ficará caracterizado o crime em tela. Haverá necessidade de um animus associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira, *societas sceleris*, em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado. Excluído, pois, está o crime, no caso de convergência ocasional de vontades para a prática de determinado delito, que estabeleceria a co-autoria." (Lei de Drogas Anotada, 2ª edição, Editora Saraiva, pág. 128).

No caso sob análise, embora tenha sido demonstrado que os réus agiram previamente ajustados, inclusive com envolvimento de dois menores de idade, não há qualquer elemento que aponte para uma intenção de associarem-se para o tráfico. Assim, somente restou demonstrada a ocorrência da coautoria. Isso porque em ambas as ocasiões em que a ré Janaína foi interrogada, afirmou que foi a primeira vez que esteve no local, inclusive os outros envolvidos relataram que não a conheciam. De modo que não há nos autos prova suficiente de que estivessem os acusados associados. Inexiste prova da estabilidade da associação, nem mesmo ficou demonstrado com a prova produzida, como seria de rigor, a presença do dolo específico, ou seja, a associação para a prática do crime em questão e a comunhão de esforços dos envolvidos, de forma permanente, muito menos que os réus se conheciam antes dos fatos.

De modo que a absolvição dos réus em relação a esse delito é medida que se impõe. Nos termos da manifestação ministerial, e em razão do aditamento da inicial acusatória de fls. 325/333, não há que se falar na prática do crime previsto no artigo 244-B do ECA, eis que o concurso de pessoas com os adolescentes será considerado para a incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas, razão pela qual devem os acusados serem absolvidos do delito, a fim de que não se caracterize *bis in idem*.

Destarte, comprovadas a autoria e a materialidade, inexistindo causa de exclusão da ilicitude, a ação penal é parcialmente procedente.

1. Passo, pois, à dosagem da pena em relação à corré JANAINA DE ANDRADE LEAL, artigo 33, caput, c.c. art. 40, inciso III e VI, todos da Lei nº 11.343/2006.

1.A) Pena-base: 5 anos de reclusão e, 500 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. A1) Culpabilidade (reprovabilidade da conduta) e consequências: Há determinação legal para que o magistrado considere na primeira fase de dosimetria da pena, a natureza/quantidade da droga, circunstâncias que indicam maior reprovabilidade da conduta do réu e por via de consequência, maiores danos à saúde pública. No caso dos autos, tratando-se de tráfico de cocaína, maconha, crack e ecstasy, entendo por exasperar a pena-base em 1/3, resultando em 6 anos e 8 meses de reclusão, e pagamento de 666 dias-multa. A2) Conduta social, motivos, personalidade e circunstâncias: nada de conclusivo apurado. A3) Comportamento da vítima: sem influência na dosagem da pena. A4) Antecedentes: a ré não possui antecedentes, conforme certificam os documentos de fls. 95.

Em se tratando de delito submetido a Lei de Drogas, o conteúdo do artigo 42 do diploma dispõe que: O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Precedentes do STF: vg. HC 126.055, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 122.299, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 118.389, Rel. Min. Teori Zavascki.

Anoto que: a Cocaína é substância entorpecente, altamente viciante que afeta o sistema neurológico e imunológico de forma irreversível, e, além de transformações internas, o uso constante causa uma degradação física evidente; no que se refere ao crack - especialistas classificam como a terceira droga mais prejudicial ao usuário, apesar de ser derivado da cocaína, o crack, pelo fato de ser consumido por meio de fumo tem seus efeitos ainda mais potentes e duram períodos mais curtos, o que gera o consumo de maiores quantidades; a heroína - é considerada como uma das drogas mais viciantes e perigosas do mundo pela OMS (Organização Mundial da Saúde) isso pelo seu alto nível de vício e dependência, ademais, diminui a frequência cardíaca o que caracteriza grande riscos de o consumidor sofrer uma overdose.

Quanto a fração a ser aumentada, é sabido que não há previsão legal valorando o quantum, ficando a critério do magistrado analisando o caso concreto. Desta forma: "o magistrado fixa a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no REsp n. 143.071/AM, Sexta Turma, Rel^a. Min^a. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 6/5/2015).

Destaco que, respeitado posicionamento diverso, entendo que a natureza da droga deve ser considerada nessa fase inicial, autorizando-se que o réu seja beneficiado com eventual atenuante ou causa de diminuição de pena, caso incorra na hipótese. Assim, estará sendo alcançada uma justa individualização da pena, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Por outro lado, filio-me à orientação de que a quantidade de droga nos dá parâmetro para análise da causa de diminuição do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, salvo em casos em que estiver presente os maus antecedentes e/ou a reincidência que já revela a trajetória criminosa do